

1500165-79.2022.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia da Conceição Santos

Comarca: Tabapuã

Foro: Foro de Tabapuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/06/2022

... à certa profissionalização do acusado no narcotráfico, considerando que as organizações criminosas afetas ao tráfico de entorpecentes, ao captarem pessoas para o transporte das drogas (as intituladas "mulas"), não entregam alta quantidade de entorpecentes logo na primeira viagem, ocorrendo o aumento de forma gradual. Portanto, não prospera a alegação do réu de que foi a primeira vez ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tabapuã

Foro de Tabapuã

Vara Única

Rua Eugenio Ulian, 1265, Tabapua - SP - cep 15880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500165-79.2022.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-79.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL LUGO ACOSTA

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra EZEQUIEL LUGO ACOSTA, dando-o como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque ele, no dia 26 de março de 2022, por volta de 07h15min, na Rodovia SP 310, KM 397+500m, Catiguá, transportou 317 (trezentos e dezessete) tijolos de maconha, com peso líquido de 296,05 kg, destinada a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticado entre Estados da Federação.

Houve a prisão em flagrante delito (fls. 05/06).

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva ao acusado (fls. 59/63).

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2022 (fls. 89/91).

Citado (fl. 104), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 113/118).

Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 127/128).

Durante audiência ouviram-se testemunhas de acusação e um informante, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, houve debates orais.

O Ministério Público pediu a procedência da ação penal, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição dos acusados, ou, subsidiariamente, a aplicação do

redutor disposto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixação da pena mínima.

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi representado por Defensora, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa. À minguia de questões processuais ou preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Durante a persecutio criminis, o Ministério Público conseguiu demonstrar a existência do crime mediante boletim de ocorrência (fls. 44/46), nota de culpa (fl. 10), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo preliminar (fls. 28/30), laudo toxicológico definitivo (fls. 76/78) e relatório final (fls. 73/74), tendo sido todos esses documentos confirmados por coerente prova oral. Quanto à autoria, esta também ficou demonstrada por robusta e uniforme prova testemunhal.

Segundo consta dos autos, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina na Praça de Pedágio de Catiguá, quando por lá passou o veículo Fiat/Palio, cor prata, ano 2004, placa HDM7B14, sentido Interior/Capital, conduzido por Ezequiel.

Após passar pelo Pedágio e receber sinal de parada, o acusado saiu em disparada com o veículo em fuga, sendo perseguido pela viatura policial. Após alguns metros de perseguição, o denunciado adentrou em uma estrada de terra e, parando o veículo em uma mata, desceu do carro e saiu correndo.

Depois de um período de perseguição a pé, os Policiais conseguiram deter Ezequiel, que contou aos policiais que tinha tijolos de maconha em seu veículo e que estava vindo de Ponta Porã/MS onde reside, com destino a São Carlos/SP.

Em revista no veículo, que estava sem os bancos traseiros, os Policiais localizaram no interior 317 tijolos de maconha, além de um rádio comunicador. Com o denunciado, os Policiais apreenderam dois aparelhos celulares e a quantia de R\$59,00 (cinquenta e nove reais).

Com efeito, a testemunha Everton Aparecido Pereira dos Santos, em solo policial, declarou ser Policial Militar rodoviário e, na data dos fatos, na companhia de seu colega de farda Cabo Silvestre, efetuavam fiscalização no Pedágio de Catiguá, na Rodovia Washington, quando um veículo Fiat Palio, cor prata, que transitava sentido interior-capital, logo após pagar o pedágio, não obedeceu ao sinal de parada para fiscalização e empreendeu fuga. Iniciaram o acompanhamento do veículo, o qual adentrou numa estrada térrea, ainda na zona rural de Catiguá. Após alguns metros, o veículo parou numa mata e o condutor saiu correndo. Conseguiram deter o homem, identificado como Ezequiel Lugo Acosta. Questionado, ele confessou que transportava drogas (maconha) da cidade de Ponta Porã, onde ele residiria, a São Carlos-SP, ocasião em que receberia pelo serviço R\$ 10.000,00. O detido não disse quem seria os fornecedores e quem iria receber a droga. Fizeram a vistoria do veículo e confirmaram que havia no interior (que estava sem os bancos traseiros) 317 tijolos de maconha. No veículo também tinha um rádio comunicador. Também foi apreendido na posse do acusado, dois celulares e R\$ 59,00 em dinheiro. Foi dada voz de prisão ao detido, sendo que o acusado não resistiu, sendo encaminhado ao Plantão Policial. Relatou que o denunciado possuía algumas escoriações pelo corpo em virtude de ferimentos que sofreu quando adentrou na mata (fl.07).

Em Juízo, declarou que estavam localizados na Praça de Pedágio do Município de Catiguá quando então deram sinal de parada obrigatória para um veículo Fiat Palio, na cor Prata, sendo que o condutor, posteriormente identificado como Ezequiel, não acatou o sinal e empreendeu fuga, a qual perdurou 2km. Em seguida, o acusado adentrou em uma estrada de terra e, com o veículo ainda em movimento, saltou e iniciou a fuga a pé em uma mata ali próxima, sendo detido pela equipe em seguida. Indagado sobre o motivo pelo qual havia corrido, o acusado informou ao declarante que estava transportando drogas. Em vistoria, localizaram no porta-malas e também na parte traseira do veículo, que estava sem os bancos, coberto com um pano, tijolos de maconha. Indagado a respeito, o réu disse que estava fazendo o

transporte da cidade de Ponta Porã- MS e queria deixar em São Carlos-SP. Receberia a quantia de R\$10.000,00 para fazer esse transporte. No veículo, também foi localizado um rádio comunicador, que estava ligado em uma frequência e o réu disse que era para manter contato com um veículo à frente, na função de batedor, mas não apresentou mais detalhes sobre quem fazia esse trabalho. Foi dada voz de prisão e no momento de sua prisão, o denunciado informou que receberia o valor de R\$10.000,00 pelo transporte de Ponta Porã a São Carlos. Não informou o tempo de residência em Ponta Porã, mas não entrou em detalhes sobre o que fazia na cidade, alegando que estava desempregado. Explicou que estavam em fiscalização de trânsito e selecionavam alguns veículos para fazer a fiscalização. Os agentes fizeram o sinal de parada, visto que o denunciado não obedeceu e isso despertou ainda mais a suspeita em relação ao veículo. Para as abordagens, são utilizados vários critérios, como cidade do veículo, expressão do condutor, procuram sempre realizar uma abordagem boa. A postura do réu despertou a desconfiança dos agentes, pois perceberam que a feição dele mudou. A placa do veículo era de São Paulo. Geralmente quando o agente está irregular, ao perceber a presença da Polícia, acabam se assustando. Por ser uma grande quantia de carregamento, o peso fez com que a traseira do carro ficasse um pouco arriada. O acusado confirmou que receberia R\$10.000,00 pelo transporte. O declarante não se recorda se Ezequiel disse que era a primeira vez. Em média, dependendo da situação, o preço do quilo da droga é de R\$1.500,00 a R\$2.000,00. Acredita que essa quantidade beira cerca de R\$300.000,00/R\$500.000,00. A respeito da grande quantidade, o declarante afirmou que é comum o agente já estar envolvido no crime e participar de organizações criminosas.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Leonardo Silvestre Pereira de Souza, Policial Militar Rodoviário, em solo policial (fl. 08).

Em Juízo, disse que estavam em patrulhamento pela Praça de Pedágio de Catiguá, quando foi dado sinal de parada obrigatória assim que o veículo saiu da cabine de pedágio de pagamento. Alegou que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo ao sinal de parada e de pronto iniciaram o acompanhamento em alta velocidade. O indivíduo então saiu da rodovia e adentrou em uma estrada de terra, momento em que ele andou por alguns metros e pulou do veículo, ainda em movimento, e empregou-se na mata. Fizeram a perseguição do averiguado e conseguiram fazer a prisão, sendo que ao ser questionado do que havia no interior do veículo, disse que era maconha, e que viajava de Ponta Porã e estava levando essa droga até o município de São Carlos. O réu informou ao declarante que receberia pelo serviço o valor de R\$10.000,00. Fizeram a vistoria do veículo, no qual foi constatada toda a droga que estava no banco traseiro, coberto por um pano. Na vistoria veicular, o declarante identificou que estava oculto embaixo do painel, do lado do motorista, um rádio comunicador, e indagado esse rádio comunicador ligado em uma frequência, o denunciado disse que estava mantendo contato com outros veículos que estavam na sua frente e faziam a função de batedor da droga. Contou que o denunciado não informou quem era a pessoa que estava fazendo o serviço junto com ele. Disse que foi dada a voz de prisão. O carro estava sem os bancos traseiros e a droga estava por baixo de um pano preto. Praticamente a parte de trás toda e o porta malas estavam carregados de drogas. O réu disse que vinha de Ponta Porã com destino a São Carlos e ganharia R\$10.000,00 pela entrega da droga. Explicou que na região costumam vender o tijolo de maconha a R\$1.500,00 a R\$2.000,00, mas pela proporção deve ser um valor grande, aproxima-se de R\$700.000,00. Não receberam informações anteriores sobre o transporte dos entorpecentes e estavam em uma fiscalização, a princípio, de trânsito. Esclareceu que costumavam fazer paradas/fiscalizações em determinados pontos estratégicos, principalmente em locais que tenham facilidade devido o fluxo de trânsito reduzido e possua certa segurança, uma iluminação boa, e a Praça de Pedágio é o local adequado para estarem abordando os veículos. Sempre iniciam a fiscalização de trânsito, posteriormente vão identificando alvo que possam demonstrar algo de ilícito que o condutor possa estar transportando. Na escolha do automóvel para fazerem a abordagem, existem vários indícios, principalmente quando abordam pessoas de outros estados. Os indícios sempre demonstram que a pessoa está irregularizada. Também são feitas paradas em veículos com placas que não possuem o

nome do estado. Reforçou que não houve tempo para abordagem, pois o acusado já percebeu que seria abordado e iniciou a arrancada brusca, momento em que os policiais iniciaram o acompanhamento, fato esse que levantou suspeita. Não conseguiram consultar a placa do veículo. O acusado informou para o declarante que era a primeira vez em que estava praticando o transporte. Explicou que é difícil a entrega de um valor tão alto para uma pessoa de primeira viagem, pois para entrar no meio criminal, o indivíduo deve ter algo que fundamente a confiança do crime organizado. Não é qualquer pessoa que consegue se infiltrar no crime organizado. Acredita que o acusado possui experiência e que não tenha sido a primeira vez. Antônio Arnaldo Martins Quevedo, ouvido como informante, declarou que foi patrão do réu, trabalharam juntos de 2016 a 2020/2021. Foi um empregado muito bom, inclusive o declarante alegou ter mudado de ramo e mesmo assim repassava trabalho para o acusado. Contou que Ezequiel sempre foi trabalhador e pontual. Quando começaram a trabalhar juntos, o réu tinha 16/17 anos de idade, era como se fosse um filho para o declarante, chegando até ficar surpreso quando ficou sabendo que o denunciado estava preso. Esclareceu que o tempo em que Ezequiel trabalhou junto com o declarante, ele nunca se envolveu com pessoas erradas, o que acredita. Relatou que o denunciado era pontual, sempre chegava no horário, geralmente almoçavam juntos. Acredita que tenha sido más companhias, pois, até onde o declarante sabe, o acusado é uma pessoa muito certa. Explicou que quando começaram a trabalhar juntos, o réu não falava português e residia com seu pai. Reforçou que Ezequiel é trabalhador e que todos os patrões gostavam dele. Ele prestava serviços em Ponta Porã, inclusive com pessoas de posses, sempre deixando o denunciado dentro das casas e ele nunca mexeu em nada de ninguém. Não sabe dizer o que o levou o réu a cometer os fatos. Os serviços que ele fazia eram de pinturas de casas. Ezequiel não possui filhos e sempre foi solteiro. Trabalharam juntos de 2016 até início de 2020/21, depois disso mudou de profissão e as pessoas o procuravam e o declarante indicava o denunciado, porque todos gostavam dele. Sempre avistava Ezequiel na cidade. Disse que mora a 50km de Ponta Porã, abriu um estabelecimento de carro, garagem de carro. As pessoas procuravam o depoente e ele indicava o acusado para trabalhar. Contou que Ezequiel fez bastantes serviços para ele, pintou mercado, casa de amigos do declarante, todo mundo fala bem dele, questão de serviço não tem o que falar dele. O acusado Ezequiel Lugo Acosta, em solo policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio (fl. 09).

Em seu interrogatório em Juízo, declarou que fez o transporte das drogas, pois estava precisando, encontrava-se desempregado e residindo com sua mãe e seu padrasto. Precisava de dinheiro, era ruim morar lá e dormir no chão. Contou que todos os dias perguntavam para ele que dia ele iria embora, e sua mãe também não possuía condições financeiras de sustenta-lo. Precisava ajudar com dinheiro, ajudar a pagar conta de água, de luz, ajudar na alimentação, isso que o motivou a aceitar a proposta. Recebeu R\$500,00 para fazer o serviço. Morava em Ponta Porã, Bairro da Granja. Possui mais irmãos, que moram no Paraguai com o genitor, todos dos mesmos pais. Conseguiu a cidadania brasileira, pois sua genitora também conseguiu. Seu padrasto é aposentado, salvo engano com 83 anos e sua mãe é manicure. Estava desempregado, trabalhou com Antônio em 2021, morava no local de serviço. Alegou que atualmente trabalhava todos os dias e não ganhava nada. Aos finais de semana não ganhava nem R\$50,00 então trabalhava só de favor, a troco de marmita e local para morar. Conheceu a pessoa que fez a proposta do transporte no lavador em Ponta Porã. O declarante estava pedindo serviços de pinturas, pois é o que ele sabe fazer, a pessoa disse para Ezequiel que com ele o declarante iria ganhar muito dinheiro, que poderiam trabalhar juntos e que o réu mudaria de vida e alugaria uma casa para ele. Alegou que foi a primeira vez que fez o transporte. Ao ser questionado sobre a grande quantidade de drogas, o declarante disse que de início não foi informado que estaria transportando drogas, foi pedido para que levasse um carro, e em seguida voltaria de ônibus. Informou que não possuía habilitação brasileira, somente do Paraguai, mas mesmo assim a pessoa insistiu para que o declarante fizesse o serviço, inclusive pagou a quantia de R\$500,00 para poder levar o carro, como forma de adiantamento, visto que o depoente não possuía nada. Ficou sabendo que transportaria drogas somente uma semana antes dos fatos. Foi combinado de receber o

pagamento, no valor de R\$10.000,00, quando fizesse a entrega do veículo na cidade de São Carlos. Foi informado que quando completasse a tarefa, ficaria em um hotel e receberia o pagamento. Contou que a pessoa insistiu muito para que o declarante fizesse o serviço, principalmente pelo fato de não ter passagem pela polícia. Não possui habilitação brasileira, até chegou a tentar tirar, mas a pandemia atrapalhou seus planos. Não sabe como vai ser quando sair do presídio, mas explica que as pessoas que estavam por dentro da viagem não entraram em contato com ele. Pois bem.

As provas coligidas aos autos são firmes a indicar a responsabilidade criminal do réu. Isso porque as testemunhas foram enfáticas e categóricas ao afirmarem que encontraram enorme quantidade de maconha em poder do réu, que transportava a droga do Município de Ponta Porã-MS para São Carlos-SP, o que foi confirmado pelo acusado e informou que receberia R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.

Ressalte-se que a abordagem policial decorreu da forte suspeita de estar o acusado praticando delito, visto que fugiu da abordagem policial quando determinada a ordem de parada e adentrou em uma mata, empreendendo fuga a pé, sendo capturado posteriormente pelos Policiais Militares Rodoviários. O Policial Everton informou ainda que o veículo estava com a parte traseira rebaixada, o que não é comum para um automóvel com apenas um passageiro, o que também chamou a atenção dos agentes de segurança. Assim, sem máculas a abordagem dos Policiais, ante o permissivo disposto no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Ante a enorme e considerável quantidade de entorpecente encontrada, no total de 317 tijolos de maconha, com peso líquido de 296,05 quilogramas (laudo de fls. 28/30 e 76/78), deduz-se que o réu possui amplo envolvimento em prática delitiva, inclusive pela quantia que receberia pelo transporte das drogas, ou seja, R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Chama a atenção que a quantidade e natureza da droga induz, inclusive, à certa profissionalização do acusado no narcotráfico, considerando que as organizações criminosas afetas ao tráfico de entorpecentes, ao captarem pessoas para o transporte das drogas (as intituladas “mulas”), não entregam alta quantidade de entorpecentes logo na primeira viagem, ocorrendo o aumento de forma gradual. Portanto, não prospera a alegação do réu de que foi a primeira vez que efetuou o transporte da droga. O fato de haver um rádio comunicador em sua posse e estar sendo “escortado” por outro veículo confirma a profissionalização da ação e seu envolvimento com práticas delituosas, também por ter tentado se eximir da abordagem policial, adentrando em uma mata e pulado do veículo ainda em movimento.

Sobreleva consignar que, pelas regras de experiência comum, em média, a porção de maconha, a depender da qualidade, é vendida por R\$ 5,00 (cinco reais) a R\$ 10,00 (dez reais) e que segundo a decisão publicada na RT 546/327, para a confecção de um cigarro de maconha são necessários 0,33 gramas, o que indica que a maconha que estava com o réu era suficiente para a confecção de quase um milhão de porções da droga. Tal assertiva deriva do seguinte entendimento: “por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Assim o “prejuízo” para a organização criminosas, neste caso, foi de milhões de reais, isso considerando a venda no preço acima mencionado e como bem ponderado pelo Policial Militar Rodoviário Leonardo Silvestre, não haveria a entrega dessa enorme quantidade de entorpecentes para alguém que fosse inexperiente na empreitada criminosas.

Vale ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de “transportar” os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Realmente, o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse dela pelo agente para fim de entrega e consumo a

terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja flagrado vendendo o tóxico.

Note-se que:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).

Assim, plenamente amoldada a conduta do denunciado ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada, visto que foi encontrado com imensa quantidade de entorpecente, sendo 317 tijolos de maconha, com peso líquido de 296,05 quilogramas (laudo de fls. 28/30 e 76/78). Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao tráfico de drogas diante das provas produzidas.

Por fim, plenamente caracterizada, ainda, a causa de aumento específica ante a caracterização do tráfico entre Estados da Federação (artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), visto que o acusado transportou os entorpecentes de Ponta Porã-MS com destino a São Carlos-SP. Assim sendo, considero o réu como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, não havendo causas que excluam a imputabilidade do réu ou o isentem de pena, de rigor a condenação nos termos constantes na peça inicial acusatória.

Passo à dosimetria da pena:

O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Pode o Juiz, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correta, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos limites legais. Deve, assim, ajustar o “quantum” da sanção e a sua modalidade, no que endente ser necessário e suficiente a satisfazer a medida da justa reprovação, de acordo com os antecedentes, conduta social, personalidade, bem como tendo em vista os motivos, circunstâncias e consequências do ato.

Assim, ressalto que os aumentos e diminuições aplicados por meio de frações sobre a pena-base serão feitos sobre o intervalo de pena estabelecido entre a pena mínima e máxima, visando a uma pena mais justa, haja vista que aplicar a fração de aumento sobre a pena mínima pode gerar incongruências que não coadunam com o desejo do legislador, que fixou o intervalo justamente para atender ao princípio da individualização da pena.

No mais, oportuno realçar que o “legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado” (HC 283.706/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Ultrapassados tais esclarecimentos iniciais, passo, então, à individualização da pena.

Artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade de droga), tendo em vista que a maconha não possui grande poder viciante, mas pela imensa quantidade de droga apreendida (296,05 quilos líquidos), a conduta merece recrudesimento na aplicação da pena; quanto à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, foi aquela inerente ao crime de tráfico de drogas; o réu não possui antecedentes criminais; os

motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime. Com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, tenho-as como desfavoráveis, visto que a atitude do réu corrobora com a criminalidade na sociedade, pois o apoio ao consumo de drogas é “desencadeador” de vários outros delitos. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima. Ante tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no piso legal cada.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), de forma que atenuo a reprimenda anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal cada. Deixo de considerar a agravante disposta no art. 61, II, “j”, do Código Penal, que se refere à calamidade pública, visto que houve o arrefecimento da pandemia da Covid 19.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se a existência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação) e, não havendo causas de redução, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e torno definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à data dos fatos, por ausentes elementos hábeis a comprovar a condição financeira do acusado.

Observo não ser o caso de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que ficou comprovado o envolvimento do acusado com práticas delitivas, ante a imensa quantidade de entorpecentes apreendida e a profissionalização da atuação, que ratificam sua dedicação à atividade criminosa e impossibilita a aplicação do redutor. Tal norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que se dirige as pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância, o que não se verifica in casu. A intenção do legislador ao inserir o §4º no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 foi privilegiar aquele que praticou o tráfico como um fato isolado em sua vida e não o fez como modo de vida no escopo de enriquecimento ilícito e obtenção de lucro fácil, ou seja, animus lucrandi e modus vivendi.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados

como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais. No âmbito desta Colenda Câmara, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que "essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder". A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)". Sem grifos no original.

A benesse sob comento trata da figura do "traficante privilegiado", também chamada de "traficância menor" ou "traficância eventual", estabelecendo a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, incabível, no presente caso, a aplicação da benesse pretendida.

Ainda, para ilustrar a inviabilidade de causa de diminuição de pena:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, tratase de apreensão de 54 pedras de crack - "50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, Colenda SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, e assim porque a fixação de regime mais brando é insuficiente para a prevenção e a repressão da prática de crimes da natureza do cometido pelo acusado, suficiência que é norteadora também da fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 59, III do Código Penal). Lado outro, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade, sem olvidar sua natureza de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/90).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por não influenciar no regime inicial de cumprimento de pena.

De outro norte, o desconto imposto pela novel legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas.

Desta feita, por reputar necessária uma análise mais profunda acerca do mérito do acusado, conforme ponderações supra tecidas, deixo de fixar, também por este motivo, regime prisional diverso do fechado, conforme faculta o dispositivo elencado no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação penal para CONDENAR EZEQUIEL LUGO ACOSTA, portador da cédula de identidade RG nº 2.559.416 SSP/MS, filho de Porfirio Lugo Gonzales e Dionisia Acosta Leme, nascido em 10/12/1998, natural do Paraguai, a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, sendo que cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, na medida em que condenado a cumprir pena em regime inicial fechado e tendo respondido preso ao processo, sendo que mantê-lo solto, nesta altura, implicaria em claro prejuízo ao cumprimento da pena, o que demanda o acautelamento da ordem pública, impedindo a recidiva criminosa, ante seu envolvimento com atividades criminosas. Além disso, a concessão da liberdade ou a imposição de medida cautelar não privativa de liberdade coloca em risco a aplicação da lei penal, pois o réu, facilmente, poderá deixar o distrito da culpa. Mantenho, assim, a prisão cautelar do acusado, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado (nos termos do Comunicado CG nº 76/2016).

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora lhe defiro, por ter sido assistido por Defensora nomeada pelo Convênio OAB/DPE (fls. 119/121), observado o provimento CG nº 02/2013. Promova-se a incineração dos entorpecentes, acaso não tenha sido realizada. Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro a perda, em favor da União, do valor de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais), de dois aparelhos celulares (marca Apple e LG), de um rádio comunicador marca YAESO e do veículo Fiat/Palio Fire, Placa HDM 7B14, Chassi 9B17146752477192, conforme auto de apreensão de fls. 24/25. Expeça-se o necessário, oficiando-se ao SENAD, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Passada em julgado esta sentença:

Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Registre-se eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tabapua, 24 de junho de 2022.

Patrícia da Conceição Santos
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA